

0001155-87.2016.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME BECKER ATHERINO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... não se aplica ao crime de tráfico de drogas.

Tráfico de drogas trata-se de crime de perigo abstrato, ou seja, é prescindível a demonstração de efetiva lesão ou risco ao bem jurídico tutelado, bastando a exposição do bem jurídico a um perigo de lesão que, no caso, é presumido com a prática da conduta prevista no preceito primário da norma.

"O crime de tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

1ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita-SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001155-87.2016.8.26.0063

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 113/2016 - Delegacia de Polícia de Barra Bonita

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean Carlos Mateus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

JEAN CARLOS MATEUS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 28, caput, e 33, parágrafo 2º, ambos da Lei 11.343/2006.

Redistribuído o feito ao Juízo comum (fl.20).

Foi declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, ante a presença da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/2006 (fls.122/123).

A denúncia foi recebida em 15/07/2019 (fls.123).

O réu apresentou defesa prévia às fls.109/113. A denúncia foi recebida em 15/07/2019 (fl.123).

O réu foi citado por edital à fl.105; 137/138.

Determinado, no dia 14/11/2019, a suspensão do processo, bem como o prazo prescricional em relação ao réu Jean Carlos Mateus, nos termos do artigo 366, do CPP (fls.141/142).

O réu foi citado pessoalmente à fl.166. Diante disso, foi revogada a suspensão do

processo, bem como do prazo prescricional, pela decisão de fls.168/170. Não havendo hipótese de absolvição sumária foi designada data para realização da audiência de Instrução e Julgamento (fls.168/170). Nesta audiência foi ouvida uma testemunha comum, e, ao final, interrogado o réu. As partes apresentaram suas alegações finais, conforme mídia anexa. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que no dia 06 de abril de 2016, por volta das 21 horas e 39 minutos, na Rua Primeiro de Março, n.533, Vila São José, nesta cidade e comarca de Barra Bonita, JEAN CARLOS MATEUS, consciente e voluntariamente, auxiliou alguém ao uso indevido de droga, consistente em 01(uma) porção da substância entorpecente "Benzoilmetilecgonina", sob a forma de pedra, droga vulgarmente conhecida como "crack" e que determina dependência física e psíquica, a qual estava embalada individualmente, pesando 0,32g (trinta e dois centigramas).

A materialidade do delito restou demonstrada pelo termo circunstanciado (fls.05/07), termo de compromisso (fl.04), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.08/09), auto de exibição/apreensão (fl.10), fotografias das drogas apreendidas (fls.15/16), bem como toda a prova oral colhida. Em sede administrativa, a testemunha Emerson Pinto da Silva, policial militar, disse que "na data de hoje por volta das 21:39h, estava em patrulhamento de rotina pela Rua primeiro de março, com seu colega de farda, quando defronte ao numeral 553, avistaram um indivíduo suspeito e optaram pela abordagem e em busca pessoal localizaram no bolso do indiciado uma pedra de crack e uma porção de maconha, ambas embaladas em saquinhos plásticos; que este indivíduo se identificou como sendo Jean Carlos Mateus, confirmou ser usuário de maconha e que a pedra de crack estava levando para um colega e apontou aos policiais onde adquiriu o entorpecente, sendo a casa de numeral 553 Fundos, sendo mesmo local dos fatos; que informou que o indivíduo conhecido como Washington, que reside neste imóvel, foi a pessoa qual lhe vendeu o entorpecente; que este local foi indicado por este colega que pediu para comprar a droga e declarou que recebeu R\$5,00 para buscar a droga para seu colega". Conforme informação acostadas nos autos, a testemunha Emerson Pinto da Silva foi a óbito, impossibilitando sua oitiva em juízo.

Em fase inquisitiva, a testemunha Jose Marcelo Fatori Fadoni, policial militar, relatou que "na data de hoje por volta das 21:39h, estava em patrulhamento de rotina pela Rua primeiro de Março, com seu colega de farda, quando defronte ao numeral 553, avistaram um indivíduo suspeito e optaram pela abordagem; que em busca pessoal localizaram no bolso do indiciado uma pedra de crack e uma porção de maconha, ambas embaladas em saquinhos plásticos; que este indivíduo se identificou como sendo Jean Carlos Mateus, confirmou ser usuário de maconha e que a pedra de crack estava levando para um colega e apontou para os policiais onde adquiriu o entorpecente, sendo a casa de numeral 553 Fundos, sendo o mesmo local dos fatos; que informou que o indivíduo conhecido como Washington, que reside neste imóvel, foi a pessoa na qual lhe vendeu o entorpecente; que este local foi indicado por este colega que pediu para comprar a droga e declarou que recebeu R\$5,00 para buscar droga para seu colega".

Em juízo, a testemunha Jose Marcelo Fatori Fadoni, policial militar, aduziu que estava de serviço com seu parceiro falecido Emerson; que suspeitaram do réu que demonstrava nervosismo, mudando a direção de sentido na via; que abordaram o acusado; que encontraram uma porção de crack e outra de maconha; que o réu disse que era usuário de maconha, mas o crack seria entregue a outra pessoa; que a pessoa lhe deu cinco reais para levar a droga para terceira pessoa; que ele teria comprado de um indivíduo chamado Whashington;

Em solo policial, o réu Jean Carlos Mateus afirmou que "é usuário de maconha e que na data de hoje estava na Rua primeiro de março, defronte ao numeral 553, para adquirir droga de uma pessoa que reside aos fundos deste imóvel, sendo que lá adquiriu uma pedra de crack; que comprou a pedido de uma colega seu, que não deseja declinar o nome; que recebeu a quantia de R\$5,00 para comprar a droga; que pagou R\$10,00 à porção da droga; que quando à porção de maconha, já havia adquirido em outro local há alguns dias.

Nessa audiência, o réu Jean Carlos Mateus esclareceu que tem trinta e oito anos; que é solteiro; que não tem filhos; que trabalha como pedreiro; que está trabalhando em uma obra na rua de cima do fórum; que ganha por volta de mil e oitocentos reais; que estudou até a sexta série; que nunca foi processado; que tem conhecimento da acusação.

Quanto aos fatos alegou que os fatos ocorreram do jeito que o policial falou; que estava embriagado; que a pessoa lhe explicou o que queria e onde queria, que ele queria pedra; que era usuário de entorpecente na época; que fumava maconha; que essa pessoa pediu para o acusado comprar crack; que essa pessoa lhe deu dez reais para comprar para ele; que já havia comprado entorpecente para essa pessoa; que conhece essa pessoa do bar; que estava bem bêbado; que ele que explicou onde comprava, que era perto do bar; que se estivesse sóbrio não iria.

O delito previsto no artigo 33, parágrafo 2º, da Lei 11.343/2006, prevê a conduta do agente que induz, instiga ou auxilia alguém ao uso indevido de droga. No caso concreto, embora tenha sido o réu denunciado pelo artigo 33, parágrafo 2º, necessário se faz a aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383 do CPP, uma vez que a conduta praticada pelo acusado melhor se amolda ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A conduta do acusado de adquirir a droga e levar até o seu "colega", se amolda nas modalidades entregar a consumo e oferecer, verbos estes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O auxílio material que prevê o artigo 33, parágrafo 2º, da lei 11.343/06, não pode consistir no fornecimento em si da droga, uma vez que essa conduta configura tráfico ilícito de entorpecentes e, assim, deve o agente responder pelo artigo 33, do mesmo diploma legal. É o caso dos autos.

Nesse sentido, a conduta do réu de ir até o local dos fatos e comprar a droga para fornecê-la ao consumo de terceiros, ora seu "colega", sofre melhor adequação típica no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Necessário ressaltar que o próprio tipo penal do artigo 33 prevê a prescindibilidade de obtenção de vantagem econômica por parte do agente. Nesse sentido, o tráfico se aperfeiçoa ainda que a entrega ou o fornecimento da droga seja gratuito, como foi caso dos autos.

Quanto ao fenômeno da emendatio libelli, este encontra-se previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal:

"Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave."

No caso, conforme já supracitado, há a necessidade de aplicação do instituto previsto no artigo 383 do CPP, uma vez que os fatos, conforme já explanado, possuem melhor capitulação jurídica no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Necessário esclarecer que não houve qualquer modificação na descrição do fato que consta na denúncia. Os fatos são os mesmos, o que impede a aplicação da mutatio libelli. O que houve no caso, é uma definição jurídica diversa da conduta descrita na inicial acusatória, não mudança fática.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. MOMENTO ADEQUADO. SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O momento adequado para se aplicar a emendatio libelli é ao tempo da prolação da sentença, porque o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal nela contida, dotada de caráter provisório. 2. Em situações assemelhadas à dos autos e em caráter excepcional, a "jurisprudência e doutrina apontam no sentido da anuência com a antecipação da emendatio libelli, nas hipóteses em que a inadequada subsunção típica macular a competência absoluta, o adequado procedimento ou restringir benefícios penais por excesso de acusação" (STJ - AgRg no REsp: 1396890 RN 2013/0287639-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2018)

Ademais, o acusado, ao oferecer defesa prévia às fls.109/113, se defendeu dos fatos contidos na denúncia, fatos estes que não sofreram qualquer alteração.

Por fim, o artigo 383 do Código de Processo Penal, deixa claro sobre a possibilidade de emendatio libelli mesmo que em virtude disso seja aplicada pena mais grave, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

Ademais, o acusado confessou esses fatos. Disse que comprou a droga a pedido de um colega e que para isso recebeu a quantia de R\$5,00. Afirmou ainda que estava levando a pedra de crack para o colega. Reitero, a conduta pratica se aperfeiçoa, perfeitamente, na conduta descrita no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto à possível atipicidade material da conduta, esta merece ser melhor analisada.

Foi apreendido com o acusado uma pedra de crack, pesando 0,32 gramas. Embora se trate de quantidade ínfima, prevalece o entendimento jurisprudencial e doutrinário que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de trafico de drogas. Trafico de drogas trata-se de crime de perigo abstrato, ou seja, é prescindível a demonstração de efetiva lesão ou risco ao bem jurídico tutelado, bastando a exposição do bem jurídico a um perigo de lesão que, no caso, é presumido com a pratica da conduta prevista no preceito primário da norma.

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). Assim, por se tratar de crime de perigo abstrato, embora a quantidade ínfima de entorpecente subsiste a relevância penal da conduta. Ademais, o bem jurídico tutelado no trafico de drogas é a saúde pública.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DIANTE DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDUTA TÍPICA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. “Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida” (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 693.572/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

Assim, devidamente demonstrada a tipicidade material da conduta e afastado o princípio da bagatela, sendo irrelevante para esse fim a quantidade de droga apreendida.

Vale ressaltar que, embora presente a tipicidade material, esta não impede o reconhecimento do trafico privilegiado, que será melhor analisado no processo trifásico de dosimetria da pena.

Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda ou inexistir qualquer anotação com a contabilidade do tráfico ou dinheiro apreendido nos autos, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico.

Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolvem o acusado.

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de

certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542). Ainda, é irrelevante a condição de usuário do acusado. Não raras são as vezes que traficantes de entorpecentes são, de igual modo, usuários e, inclusive, comercializam entorpecentes de modo a angariar fundos para a compra dos mesmos entorpecentes. Ademais, mesmo que o acusado não tenha obtido qualquer proveito econômico, praticou os verbos previstos no tipo penal.

Não há qualquer dúvida a cerca do destino do entorpecente. O próprio acusado relatou em seu depoimento que a droga encontrada consigo, durante a busca pessoal, era destinada a consumo de terceiro.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes, ainda que gratuita. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

Assim, porque comprovada a prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do requerido por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas, nos termos do artigo 59 do Código penal e 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias agravantes. Presente por outro lado a circunstância atenuante da confissão. Ocorre que a pena já foi fixada no patamar mínimo, razão pela qual não é possível maior diminuição nesta fase. Fixo, assim, a pena intermediária em 05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa.

Na ultima fase, ausentes causas de aumento de pena. No entanto, verifico que o réu faz jus ao benéfico do trafico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que é primário e não há presente circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, diminuo a pena em 2/3, diante da ínfima quantidade de droga apreendida. Por essa razão, fixo a pena definitiva em 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Inexistindo elementos suficientes para reconhecer a capacidade financeira do réu, fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional.

Na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente aberto, porque se trata de réu primário, sem antecedentes, cujas circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (artigo 44, inciso III, do Código Penal). Por essa razão, substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e, ainda, prestação de serviços comunitários pelo prazo da condenação, à razão de seis horas semanais.

Ante o exposto, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal, procedo à emendatio libelli e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu JEAN CARLOS MATEUS ao cumprimento da pena de 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, por infração ao disposto no artigo 33, caput, combinado com seu parágrafo 4º, todos da Lei 11.343/06. Contudo, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e, ainda, prestação de serviços comunitários pelo prazo da condenação, à razão de seis horas semanais.

Como assim respondeu ao presente feito, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/03, ressalvada a gratuidade da Justiça.

Fixo os honorários advocatícios em 70% da tabela, expedindo-se o necessário desde

logo e ficando o restante a ser apreciado quando do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, (i) intime-se o réu para o pagamento da pena de multa; (ii) expeça-se a guia de execução definitiva; (iii) expeça-se ofício ao IIRGD e ao TRE.

Nada mais havendo a ser tratado, regularizem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Barra Bonita, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA